

1501630-56.2020.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ADRIANO PINTO DE OLIVEIRA

Comarca: Birigui

Foro: Foro de Birigui

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/01/2022

... está a exigir especial rigor no combate a seu tráfico, impondo-se, em consequência, a aplicação aos traficantes de reprimendas penais de severidade correspondente ao elevado risco que a nefanda mercancia acarreta à saúde pública" (TJRS - AC - 687055624 - Rel. Alberto de Moraes Lacerda - RJTJRS 130/154)

PENA - Agravantes - Tráfico de entorpecentes - Associação - Hipótese ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Birigui

Foro de Birigui

1ª Vara Criminal

Rua Faustino Segura nº 214, Birigui-SP - cep 16200-370

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501630-56.2020.8.26.0603 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501630-56.2020.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2283549/2020 - DEL.POL.PLANTÃO BIRIGUI, 14672998 -

DEL.POL.PLANTÃO BIRIGUI, 3554/20/309 - DEL.POL.PLANTÃO BIRIGUI, 2283549 -

DEL.POL.PLANTÃO BIRIGUI, 2283549 - DEL.POL.BIRIGUI, 3554/20/309 - DEL.POL.BIRIGUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ISABELE GARCIA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ADRIANO PINTO DE OLIVEIRA

S E N T E N Ç A

Processo nº 1501630-56.2020.8.26.0603 (Controle 1947/2021)

VISTOS.

ISABELE GARCIA DA SILVA, qualificada nos autos, foi presa em flagrante delito, denunciada e viu-se processada como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 13 de Novembro de 2020, por volta das 11h45min, no imóvel

localizado à Rua Ataíde Gajardoni, nº 1031, Portal da Pérola II, nesta cidade e comarca de Birigui, guardava e tinha em depósito 824,98 gramas de maconha e 181,75 gramas de cocaína, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudos toxicológicos definitivos de fls. 171/176.

Oferecida a denúncia, a ré foi notificada para apresentar defesa escrita (fl. 215), cuja peça foi juntada às fls. 242/244, sobrevivendo o recebimento da denúncia em 23 de julho de 2021 (fls. 263/264).

Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos de 03 (três) testemunhas arroladas em comum, sobrevivendo, ao final, o interrogatório da acusada (fls. 287/288).

Em alegações finais, o Ministério Público pleiteou a procedência da ação, nos exatos termos da denúncia (fls. 292/297).

Já a defesa da acusada pediu que seja reconhecida a atenuante de confissão espontânea. Requereu, ademais, a fixação da pena no mínimo legal, convertendo a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos e o direito de recorrer em liberdade (fls. 306/311).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade da denunciada pela prática de conduta que, em tese, estaria a configurar o delito de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06).

A ação penal é procedente.

Ao término da instrução criminal, e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria dos fatos narrados na denúncia ficaram satisfatoriamente comprovadas.

Nesse sentido, temos: o auto de prisão em flagrante (fls. 01/02); a nota de culpa (fl. 26); o boletim de ocorrência (fls. 10/13); o auto de apreensão e exibição (fls. 24/25); os autos de constatação prévia (fls. 51/52); os laudos periciais (fls. 171/173 e 174/176); o relatório policial (fls. 163/164); os depoimentos das testemunhas; e a confissão apresentada pela acusada, em ambas as fases da persecução penal.

A acusada, na delegacia e em juízo, alegou que informou aos policiais que tinha 4 pinos de cocaína no seu quarto, bem como um saco plástico transparente com 50 gramas de cocaína, pronta para o consumo, que estava no criado mudo do quarto. Os policiais encontraram uma balança de precisão, mas estava quebrada. O dinheiro localizado era oriundo do restante do auxílio emergencial. Confirma que a droga encontrada era para uso pessoal e também para comércio e que os objetos enterrados no quintal eram destinados a fabricação caseira de drogas. Afirmou que Ledislaine não sabia que traficava drogas, apenas usavam entorpecentes juntas (fls. 07/08 e 287/288).

Em juízo, continuou a confirmar a prática criminosa, afirmando que estava vendendo entorpecentes porque passava por dificuldades financeiras (fls. 287/288).

Como se vê a acusada, em ambas as fases, confessou a prática do tráfico de drogas, apesar de alegar que o fez por estado de necessidade.

A confissão livre e espontânea prestada no processo, serve como importante elemento de convicção para evidenciar a autoria e amparar a condenação, quando encontrar sustentação nos demais elementos de convicção produzidos.

De fato, no caso, a confissão da ré encontrou total respaldo nas demais provas carreadas aos autos.

Com efeito, os policiais militares Marcelo Alberto dos Santos e Willian Ricardo Brazoloto, ouvidos em ambas as fases, relataram que recebeu denúncia do tráfico de drogas na Rua Ataíde Gajardoni, nº 1031. Dirigiram-se ao local e a acusada e a testemunha Ledislaine estavam na frente do imóvel. Quando elas avistaram os policiais, correram para o interior da casa. Adentraram na residência e localizaram na sala, ao lado da TV, 58 pinos plásticos de cor verde, contendo cocaína. A acusada Isabele informou que no seu quarto havia mais drogas e lá encontraram outros eppendorfs, de cor preta, contendo cocaína e R\$ 154,00 em dinheiro e um saco

contendo pinos de plástico de cor preta. No quintal, localizaram mais dois tambores plásticos contendo três porções de maconha, pesando 700 gramas. O outro tambor continha martelos, facas e rolos de filme plástico. No balcão existente entre a cozinha e a sala, havia uma balança digital e sob a bandeja da balança, um saco plástico com 18 gramas de cocaína (fls. 03/04, 05/06 e 287/288). Em juízo, os policiais afirmaram que a acusada assumiu a propriedade das drogas localizadas (fls. 287/288).

O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Tal depoimento somente não terá valor quando se evidenciar o interesse do servidor na investigação penal, e quando suas declarações não encontrarem suporte em outros elementos probatórios idôneos. Importante salientar que não existe qualquer circunstância que justificasse o interesse das testemunhas em prejudicar a acusada, ou em imputar falsamente a ela a prática de conduta definida como crime, sobretudo porque ela não apontou nada que justificasse essa circunstância. Por fim, a testemunha Ledislaine Nascimento dos Santos, ouvida nas duas fases, disse que é usuária de drogas e estava na casa da ré fumando maconha quando os policiais chegaram e localizaram os entorpecentes. Não sabia que Isabela tinha mais drogas na residência (fls. 09 e 287/288). De outra parte, a diversidade e quantidade dos entorpecentes apreendidos (maconha e cocaína); as circunstâncias da abordagem da ré (denúncia de tráfico de drogas na residência), a forma de acondicionamento da droga (distribuídos em porções, embaladas, prontas para o comércio), a apreensão de balança, fita crepe, rolo plástico, dois martelos, faca, celular, bem como a confissão da ré em ambas as fases, estão a caracterizar a traficância. As substâncias apreendidas consistem realmente em “maconha” e “cocaína” (exames químicos-toxicológicos de fls. 171/173 e 174/176). Nunca é demais lembrar que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente guarde e tenha em depósito para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado. No caso, a ré foi denunciada porque guardava e tinha em depósito a droga, para a venda a terceiros. Assim, além da robusta prova acima analisada, há indícios mais que suficientes para a prolação de decreto condenatório. Aliás, neste ponto, tratando-se de delito, na maioria das vezes, praticado às escondidas, não se pode abrir mão dos indícios para o estabelecimento da verdade real. E a definição de indício vem estabelecida no próprio Código de Processo Penal, no artigo 239. Com isso, constata-se que o juiz formará a sua convicção na livre apreciação da prova, e, diante do nosso sistema processual, o indício é o fato provado que, por sua ligação íntima com o fato probando, autoriza a concluir algo sobre este, até porque os indícios estão inscritos no título da prova, e, assim, a autoria do delito, pelo sistema do livre convencimento, pode ser demonstrada, validamente, pela força probante dos indícios. Sendo assim, não resta dúvida de que no dia, horário e local indicados na denúncia, a acusada guardava e tinha em depósito 824,98 gramas de maconha e 181,75 gramas de cocaína, substância entorpecente determinante de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para entrega a consumo de terceiros. A conduta da ré encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06. Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade da denunciada ou extingam a punibilidade da agente. Neste ponto, embora a acusada tenha alegado que era usuária de drogas, tais alegações não restaram comprovadas, pelo contrário, foram afastadas pelas provas colhidas durante a instrução, que confirmaram a prática do tráfico de drogas pela acusada. Ressalto que, ainda que se demonstrasse tal fato, isso, por si só, não lhe impede de exercer a traficância. Muito pelo contrário, há grande afinidade entre uma e

outra conduta. Se a ré é viciada há um bom tempo, isso facilita o ingresso no submundo do crime, principalmente no mercado de substâncias tóxicas. Diante desse quadro, a condição de ser o agente usuário não exclui a possibilidade de ser condenado como traficante, porque são situações que não se excluem. Ademais, não há como reconhecer eventual estado de necessidade, já que não vislumbro a presença do perigo atual, como exigido pelo artigo 24, caput, do Código Penal, além do que poderia a ré ter realizado outras condutas lícitas que não o tráfico de drogas.

Reconheço, pois, a ocorrência do delito e passo a aplicar as penas. Não obstante a primariedade da ré, nesta fase da aplicação da pena, deve ser levado em conta que a introdução da considerável quantidade de droga no mercado, se fosse alcançada, traria efeitos altamente lesivos à sociedade. Evidente, assim, a necessidade de um maior rigor na fixação da pena-base, em patamar acima do mínimo legal, lembrando que seria absolutamente desprovido de razoabilidade apená-lo com a sanção base mínima, tratando-o igualmente, por exemplo, a quem fosse preso traficando algumas gramas daqueles entorpecentes. Essa é a posição de nossos Tribunais:

“Na avaliação das circunstâncias legais para a fixação da pena, em se tratando de tráfico de entorpecentes, devem influir decisivamente a espécie e a quantidade da droga. O tipo de entorpecente é dado que indica o grau de nocividade para a saúde pública, correlato ao indicador das conseqüências do crime; a quantidade, quase sempre, aponta para o grau de envolvimento do infrator com o odioso comércio, indicando a medida de sua personalidade perigosa e voltada para a prática criminosa” (STJ, HC 13.231-MS, 5ª T., j. 22.08.2000, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 09.10.2000 – RT 786/599).

“Nos casos de tráfico de entorpecente, a fixação da pena obedecerá aos critérios do art. 59 do CP entre eles os motivos, as circunstância e conseqüências do crime, razão pela qual se admite a fixação de pena-base acima do mínimo legal, se houve apreensão de grande quantidade de droga” (STJ, HC 11.235-SP, 5ª T., j. 16.03.2000, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 17.04.2000, RT 783/594).

“Admissível, em tema de comércio clandestino de entorpecente, é a maior severidade na repressão penal em face da natureza mais nociva ou da maior quantidade de substância tóxica apreendida” (TACRIM-SP-AC-Rel. Geraldo Pinheiro – JUTACRIM 44/293).

“A alta nocividade da cocaína está a exigir especial rigor no combate a seu tráfico, impondo-se, em conseqüência, a aplicação aos traficantes de reprimendas penais de severidade correspondente ao elevado risco que a nefanda mercancia acarreta à saúde pública” (TJRS – AC – 687055624 – Rel. Alberto de Moraes Lacerda – RJTJRS 130/154)

PENA – Agravantes – Tráfico de entorpecentes – Associação – Hipótese em que, se a Justiça Pública houvesse apelado, caberia modificação no decreto condenatório, pois a grande quantidade de entorpecente apreendida justificaria plenamente a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, além de que o “modus operandi” do casal criminoso, demonstra organização que merecia maior rigor punitivo; todavia, como não é possível “reformatio in pejus”, a pena cominada na r. sentença deve prevalecer – Preliminar rejeitada, recurso parcialmente provido. (Apelação Criminal n. 1.044.309-3/5 – São Paulo – 6ª Câmara Criminal – Relator: Marco Antonio – 23.8.2007 – V.U. – Voto n. 6.277)

Portanto, levando em conta o dado elencado, no aspecto acima relatado (quantidade da droga), fixo a pena-base acima do mínimo legal em 1/2 (metade), resultando em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no valor mínimo unitário (art. 43, caput, da Lei nº 11.343/06).

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas. Não é caso de reconhecimento da atenuante da confissão, porque a ré alegou estado de necessidade, que é uma excludente de ilicitude, procurando eximir-se de sua responsabilidade penal, lembrando que o entendimento deste Juízo é no sentido de que a confissão espontânea a que alude o artigo 65 do Código Penal, como circunstância determinante de alguma redução de pena, é aquela sem ressalvas, sem desculpas para o gesto criminoso, a qual não restou configurada no caso.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem aplicadas. Quanto à causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, embora a ré não seja reincidente, entendo não ser caso de sua incidência, porque restou demonstrado, por todos os elementos acima descritos, bem como pela apreensão de grande quantidade de drogas, de espécies diversas (nada menos do que 824,98 gramas de maconha e 181,75 gramas de cocaína, totalizando 1.006,73 gramas), que a acusada se dedicava à narcotraficância em escala expressiva, guardando e tendo em depósito grande quantidade de droga na residência apontada na denúncia, de modo que é forçoso reconhecer que se dedicava a atividade criminosa, fazendo do tráfico o seu meio de vida.

Neste sentido, já se decidiu:

“ Sem incidência , porém, na última fase da dosagem, de retroativa redutora, por conta do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, visto que, pese a primariedade e bons antecedentes, concretamente, a forma de embalagem da droga apreendida (cerca de sessenta e cinco invólucros), sua natureza (crack) e forma de ação desenvolvida - para fim de venda a indeterminado número de pessoas - antes de caracterizar eventual pequeno tráfico, traz indicações de fazer do fato modo de vida, exercício de atividade criminosa.”

Em outros termos, a quantidade expressiva de entorpecente, inversamente ao princípio da insignificância, poderia causar consequências gravíssimas a um número imenso de pessoas, bem como denota periculosidade acentuada por parte da acusada, já que realizava o tráfico em escala considerável, o que deve ser diferenciado do pequeno traficante, sob pena de violação do primado da igualdade, razão pela qual não faz jus à redução em questão.

Torno definitiva a pena 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no valor mínimo unitário (art. 43, caput, da Lei nº 11.343/06).

Diante da gravidade da conduta, mesmo levando-se em conta a detração penal disposta na Lei nº 12.736/12 (art. 2º, que acrescentou o § 2º ao art. 387 do CPP), a pena privativa de liberdade da ré deve ser cumprida no regime inicial fechado, obrigatoriamente, pois o crime de tráfico é equiparado a hediondo, conforme estatuído no art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90.

Ademais, infere-se inviável, de igual sorte, a alteração do regime prisional, na hipótese, com esteio no lapso que perdurou a prisão cautelar, porque não se tem notícia a respeito da real situação carcerária da acusada, isto é, se não registra outras condenações ou prisões processuais, nem quanto ao seu comportamento e conduta no cárcere, a revelar não existirem elementos seguros para a correta análise, nesta seara e de pronto, quanto a eventual direito à detração penal, emergindo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, à míngua de informações concretas.

A acusada deverá continuar a responder presa por este processo, pois assim permaneceu durante a instrução e ainda estão presentes os requisitos da custódia cautelar, como se verá doravante.

Fixo cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante a ausência de informações seguras sobre a capacidade econômica da ré.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR ISABELE GARCIA DA SILVA qualificada nos autos, ao cumprimento das penas de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado (art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação da Lei nº 11.464/07), e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no menor valor (art. 43, caput, da Lei nº 11.343/06), dando-o como incurso

nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06.

Consigno que a acusada ficou presa cautelarmente desde 13/11/2020 até a presente data, período sobre o qual fica reconhecida a detração penal, para fins de cumprimento do restante da pena, nos termos do que dispõe o artigo 1º da Lei nº 12.736/12.

Deve, no entanto, a Serventia, ao expedir a Carta de Guia, atentar para se consignar a condenação total constante do dispositivo acima, com as observações consignadas no parágrafo anterior (detração penal).

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por entender incabível tal providência.

Não obstante o julgamento do Habeas Corpus n. 50394-60, pelo Supremo Tribunal Federal, no qual se entendeu por inconstitucional a vedação à substituição por penas restritivas de direitos para o crime de tráfico, por afronta ao princípio da individualização da pena, até então não se trata de decisão proferida com efeito erga omnes.

Foi editada a Resolução nº 5/2012, do Senado Federal, que, nos termos do artigo 52, inciso X, da Constituição Federal, suspendeu a execução de parte do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, que vedava de forma abstrata (sem análise do caso concreto) a conversão em penas restritivas de direito, declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo em decisão no Habeas Corpus já mencionado acima.

Com a mencionada Resolução, não se pode mais afirmar que o efeito do julgamento daquele habeas corpus não é para todos. Entretanto, a intenção do Supremo Tribunal Federal, ao decidir desta forma, e o Senado Federal, ao editar a resolução, foi somente deixar à prudente análise do magistrado do caso concreto se o réu tem ou não direito a ter a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, e não que essa substituição seja admitida em qualquer caso de tráfico de drogas, indistintamente. Pensar assim seria um contra-senso.

O fato de o caso ser enquadrado pela jurisprudência no chamado "tráfico privilegiado" não autoriza, automaticamente, a substituição da pena corporal por restritivas de direito, em razão de sua gravidade.

Confira, neste sentido, recente decisão proferida em Apelação Criminal que analisou sentença proferida por este juízo:

"... Inviável, nesse passo, a pretendida substituição carcerária por restritivas de direito, porque, embora o teor da recente Resolução nº. 5/2012 do Senado Federal, fundada na decisão do Supremo Tribunal Federal proferida nos autos do Habeas Corpus, nº. 97.256/RS – mencionado nas razões recursais –, em controle difuso de constitucionalidade, in casu, permanece impossível, data vênua, a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal, ou mesmo a concessão de sursis, pois o crime de tráfico de entorpecentes revela a gravidade peculiar que desestabiliza a vida em sociedade e fere de morte a saúde pública, pois enquanto fomenta, simultânea e irremediavelmente – até as pedras estão cansadas de saber –, a violência, a destruição de lares e das famílias e a prática de n crimes, sobretudo para o fim de viabilizá-lo, tanto assim que, por força de norma constitucional, é assemelhado aos delitos hediondos, cuja pena deve ser cumprida no regime prisional inicial fechado, determinação esta que se mostra incompatível com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou com a suspensão condicional da pena, de modo que não se consegue compreender ou avaliar, por mais que se esforce, qual seria a pena substitutiva ou as condições do sursis adequadas ao traficante, emergindo sintomático que – até o momento – jurista sério algum tenha ousado sugeri-las..." (TJ-SP, Apelação Criminal nº 0009435-15.2010.8.26.0077, 5ª Câmara Criminal, rel. Des. Juvenal Duarte, j. 19.04.2012).

Ainda no mesmo sentido, confira julgamento proferido recentemente em processo que tramitou por essa comarca de Birigui:

"Também não faz jus a apelante à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A concessão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos aos condenados a tráfico de drogas é incompatível com a gravidade e as

circunstâncias em que o crime é cometido, não havendo qualquer tipo de violação ao princípio da individualização da pena.

Este entendimento deve prevalecer, notadamente ao se considerar a vedação expressa trazida pelo artigo 44 da Lei de Drogas.

Com efeito, o benefício consistente na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos tem por objetivo primordial o de possibilitar a ressocialização de indivíduos de baixa periculosidade, que praticaram delitos de pequeno grau de lesividade social.

Traficantes de substâncias entorpecentes, sejam de pequeno, médio ou grande porte, não tem o perfil de iniciar o cumprimento de sua pena que não mediante encarceramento. Mesmo o pequeno traficante merece uma punição severa. Basta que a venda de drogas seja realizada uma única vez, para que cause uma série de malefícios ao consumidor, as quais virão a repercutir a toda a coletividade. Ressalta-se que uma das exigências previstas no artigo 44, inciso III, do Código Penal, para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é a de que os motivos e as circunstâncias indiquem como suficiente tal medida, para a repressão do agente da conduta delituosa.

Conforme já fundamentado, tal benefício não se coaduna com as graves consequências que a mercancia de substâncias entorpecentes causa, não só ao usuário, com uma rápida deterioração da sua saúde física e mental, mas também ao corpo social (desestrutura familiar, estímulo à prática de outros crimes, como homicídios, latrocínios, extorsões etc.).

Muito embora o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do "Habeas Corpus" nº 97256/RS, tenha expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", contida no § 4º, do artigo 33, da Lei 11343/06, é de se ressaltar que tal decisão não possui o erga omnis.

E mesmo a resolução nº 5 do Senado Federal, de 15 de fevereiro de 2012, que suspendeu a eficácia da referida expressão, não acarreta direito subjetivo do agente que praticou o grave delito do tráfico de entorpecentes a tal conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Frise-se, ainda, que o artigo 44 da Lei de Drogas mantém tal vedação ao crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput. Considerando que o § 4º é tão somente uma causa de diminuição do delito previsto no caput – e não um crime autônomo –, é possível concluir que a vedação a ele também se aplica.

Neste aspecto, ensina Guilherme de Souza Nucci que "(...) o fato de haver sido prevista uma causa de diminuição de pena para o traficante primário, de bons antecedentes, sem outras ligações criminosas, não afasta a tipificação da sua conduta como incursas no artigo 33, caput e § 1º, que são consideradas similares a infrações penais hediondas, como se pode observar pelas proibições enumeradas no artigo 44 da Lei 11343/06. Salienta-se, ademais, o cuidado legislativo em vedar a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, típica opção de política criminal para o tráfico ilícito de drogas. Não se pode criar uma nova infração penal, a partir da mera aplicação de causa de diminuição de pena. Por isso, o tráfico ilícito de drogas será sempre considerado equiparado a hediondo, ainda que comporte, por opção legislativa, pena mais branda, quando os requisitos do § 4º estiverem presentes" (in "Leis Penais e Processuais Penais Comentadas", 5ª ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2010, p.372).

Desta forma, NEGOU PROVIMENTO ao recurso, mantendo, integralmente, a respeitável sentença de primeiro grau" (Apelação Criminal nº 0002364-20.2014.8.26.0077. Rel. Toloza Neto).

Não bastasse todos os argumentos expostos no voto supracitado, no caso concreto, a substituição não é possível, porque a pena ultrapassou quatro anos e o crime é considerado grave e demonstra periculosidade considerável da ré, que praticava o tráfico mantendo em depósito grande quantidade de entorpecentes, o que merece maior reprovação do Poder Judiciário.

A acusada deverá continuar a responder presa a este processo, eis que sua prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, conforme decisão proferida à fls. 65/67, bem como aqueles expostos na decisão de fls. 255/257 que indeferiu pedido de

liberdade provisória.

A confirmar a necessidade da manutenção da prisão cautelar, estão as decisões proferidas no Habeas Corpus nº. 2271572-03.2020.8.26.0000, impetrado em favor da ora acusada, que teve a liminar indeferida (fls. 148/149) e, ao final, a ordem denegada (fls. 315/322), demonstrando o acerto deste Juízo na segregação cautelar do acusado.

Recomende-se a ré na prisão em que se encontra, com fundamento nos artigos 59 da Lei nº 11.343/06, c.c. o § 4º do artigo 2º da Lei nº 8.072/90, acrescentado pela Lei nº 11.464/07.

Por fim, em atenção ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, após 85 (oitenta e cinco) dias contados da publicação da sentença, tornem os autos conclusos para revisão da necessidade de manutenção ou não da decisão que manteve a prisão preventiva, mantendo-se os autos na fila "acompanhamento de prisão preventiva".

Com fundamento no artigo 58, § 1º, da Lei nº. 11.343/06, e considerando que não houve controvérsia, no curso do processo, sobre a natureza ou quantidade do entorpecente, ou sobre a regularidade do respectivo laudo, determino a incineração da droga apreendida, expedindo-se o necessário e preservando-se fração para eventual contraprova, se necessário.

Quanto aos objetos apreendidos (balança, fita crepe, rolo plástico, dois martelos, face e celular), apesar de serem instrumentos do tráfico de drogas praticado pela acusada, diante da sua natureza, entendo não ser caso de perda em favor do Senad, mas sim destruição imediata, a qual fica desde já determinada, expedindo-se o necessário e comunicando-se a Sala de Armas e Objetos Apreendidos.

Oficie-se à Delegacia de Polícia de origem, a destruição dos objetos apreendidos, instruindo-se o ofício com as cópias.

Com o trânsito em julgado da presente, oficie-se ao Cartório Eleitoral, nos termos do artigo 28 da Resolução nº 23.399/13 do TSE, instruindo o ofício com cópias da presente sentença e eventual Acórdão, bem como das certidões de trânsito em julgado para as partes.

Custas, na forma da lei.

P. R. I.

Birigui, 18 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA